

1504570-68.2021.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... de que Gabriel estava praticando tráfico nas imediações; que avistou Gabriel numa viela; que Gabriel tentou empreender fuga ao visualizar os policiais e soltou invólucro no chão; que conseguiu abordar Gabriel; que com ele havia entorpecente; que o invólucro jogado ao chão continha droga; que Gabriel confessou o tráfico no local; que, com Gabriel, havia maconha e "crack"; no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504570-68.2021.8.26.0664 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504570-68.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2312240/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 21424382 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2903/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2312240 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2312240 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 2903/21/711 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FERREIRA DE BARROS LUZ

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de GABRIEL FERREIRA DE BARROS LUZ, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c.c. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Emerge da denúncia (fls. 103/5):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 22:30 horas, na Rua Dr. Joaquim Franco Garcia, nº 1655, Jardim Eldorado, nesta cidade e Comarca, GABRIEL FERREIRA DE BARROS LUZ, nas imediações dos estabelecimentos elencados no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06,

trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico.

Determinada a notificação do denunciado (fl. 110), esta realizou-se à fl. 175. A defesa prévia foi apresentada às fls. 139/45.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 e o réu foi citado (fl. 179). Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 151/3).

Durante a instrução, colheu-se o depoimento de quatro testemunhas e, ao final, realizou-se o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão manifestada na denúncia, a fim de se condenar o denunciado como incurso no tipo penal mencionado na inicial acusatória.

A Defesa, a seu turno, postulou a absolvição por insuficiência probatória e deduziu teses subsidiárias.

É o breve relatório. Decido.

Não há preliminares ou prejudiciais ao mérito. Por outro lado, encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Em virtude disso, avanço diretamente à análise do mérito.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 prevê como crime as seguintes condutas, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa

O bem jurídico tutelado pela norma penal é a saúde pública, de forma que o delito é de perigo abstrato e se consuma com a prática efetiva de qualquer das condutas previstas no tipo incriminador. Droga, no caso, como elemento normativo do tipo, é toda substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, assim considerada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e listada na Portaria SVS/MS 344, de 12/05/98.

O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, consubstanciado na vontade e consciência de praticar uma das várias condutas nucleares do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo o agente pleno conhecimento de que a droga é entorpecente ou que causa dependência física ou psíquica, e que o faz sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, é crime de mera conduta, sendo irrelevante a prova da comercialização.

Passo a analisar os elementos de prova colhidos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao réu restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência policial (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/2), laudo preliminar de constatação (fls. 37/8), laudo definitivo de exame químico-toxicológico, indicando que foi detectada a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nos materiais analisados (fls. 92/4), laudo pericial do local (fls. 89/91), laudo do aparelho celular (fls. 119/32), fotografias (fls. 13, 14 e 15) e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual.

As substâncias em questão encontram-se presentes na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Paulo Cesar Serantoni, policial militar, disse, em juízo, que, na data dos fatos, estava patrulhando o bairro Matarazzo; que tinha denúncia de que Gabriel estava praticando tráfico nas imediações; que avistou Gabriel numa viela; que

Gabriel tentou empreender fuga ao visualizar os policiais e soltou invólucro no chão; que conseguiu abordar Gabriel; que com ele havia entorpecente; que o invólucro jogado ao chão continha droga; que Gabriel confessou o tráfico no local; que, com Gabriel, havia maconha e "crack"; no invólucro jogado por Gabriel havia maconha, "crack" e cocaína; que Gabriel estava em posse de um aparelho celular Iphone, que foi apreendido; que o local é conhecido como ponto de droga; que há escolas e igrejas próximas ao local; que já efetuou apreensão de Gabriel durante a menoridade; que, à época, Gabriel foi apreendido com grande quantidade de droga em sua casa; que sempre presenciava Gabriel no local; que, no momento do flagrante, não abordou usuário de droga; que Gabriel estava sozinho; e que, após Gabriel estar em liberdade, não o abordou, mas já o visualizou no mesmo local após a sua soltura. A testemunha Rodrigo Leandro Ferreira De Souza, policial militar, disse, em juízo, que estava em patrulhamento no bairro Matarazzo, em região conhecida pelo comércio de drogas; que Gabriel estava numa esquina e tentou evadir-se da viatura; que o policial Serantoni foi no encalço de Gabriel e conseguiu abordá-lo; que havia porção de cocaína e maconha com Gabriel; que Gabriel, quando estava tentado fugir, dispensou ao solo porções de "crack", maconha e cocaína; que conhecia Gabriel dos meios policiais; que já apreendeu Gabriel por trafico de drogas durante a menoridade; que havia denúncias de que Gabriel praticava tráfico no local da abordagem policial; que Gabriel não trabalha; que o celular apreendido com Gabriel era um Iphone; e que também houve apreensão da quantia de R\$ 70,00 com Gabriel. A testemunha de Defesa José dos Santos disse, em juízo, que é conhecido de Gabriel há dois anos; que conhece a genitora de Gabriel; que nunca viu Gabriel usar maconha; que desconhece que Gabriel pratique tráfico de drogas; que sempre vê Gabriel na residência dele; que não conhece o local da abordagem policial; que, sempre que vai à casa de Gabriel, ele está no local; que Gabriel trabalha com computador e em usina; e que não sabe se Gabriel perdeu emprego que tinha na usina. Em seu interrogatório judicial, o acusado GABRIEL FERREIRA DE BARROS LUZ negou a prática delitiva. Disse que tem 19 anos; que é solteiro; que está desempregado; que trabalhava de janeiro a dezembro de 2021, estando registrado; que não possui qualquer vício; que, quando era menor de idade, foi condenado por ato infracional de tráfico de drogas; que ficou internado por seis meses na Fundação CASA; que saiu em junho de 2020; que também já foi condenado a prestar serviços comunitários em razão de prática de ato infracional de tráfico de drogas; que não é verdadeira a acusação; que, no dia dos fatos, tinha acabado de receber seu salário; que estava com R\$ 100,00 (cem reais) no bolso; que foi para o bairro Matarazzo; que, à época, usava maconha e foi adquirir entorpecente; que comprou porção de maconha por R\$ 30,00, ficando com R\$ 70,00 de troco; que o traficante que vendia a droga gritou "olha a policia" e o interrogado correu; que os policiais cercaram o interrogado; que tirou do bolso tudo que tinha, que era a porção de maconha, o celular e a quantia de R\$ 70,00; que não sabe o nome do traficante, mas ele é conhecido como "Richinho"; que estava com celular Iphone; que apenas havia maconha no bolso do interrogado; que os policiais mentiram ao dizer que o interrogado dispensou algo no solo, mas nada tem contra eles; que não jogou nada ao chão; que o traficante não foi abordado, pois conseguiu correr da polícia; que tinha envolvimento anterior com tráfico, mas as mensagens encontradas em seu celular e encaminhadas para a namorada era por brincadeira; que não é do "corre"; e que a correria a que faz alusão nas mensagens diz respeito ao trabalho do interrogado.

Verifica-se que a negativa do acusado, de que não trazia consigo os entorpecentes para fins de tráfico, encontra-se isolada do conjunto probatório, indo de encontro às alegações dos policiais militares, os quais, em relato coeso e uníssono, afirmaram que, na data dos fatos, presenciaram o acusado próximo a local conhecido como ponto de droga, o qual, ao avistar a viatura policial, tentou evadir-se, adentrando em viela, tendo dispensado invólucro ao chão. Realizada a abordagem policial, constatou-se que Gabriel trazia consigo entorpecentes de variedade diversa, inclusive no invólucro jogado ao solo.

Os depoimentos prestados pelos policiais foram coerentes e harmônicos com os demais subsídios de convicção existentes nos autos – especialmente com o laudo de constatação da substância entorpecente – e não há nenhum indicativo a colocar em

xeque a idoneidade das informações prestadas. Em verdade, o exercício da função de agente da lei não pode, por si só, tornar suspeita a versão dos fatos apresentados, pois seria um contrassenso que o Estado incumbisse tais pessoas da função repressiva e lhes negasse crédito quando relatam suas diligências.

Ademais, o aparelho celular de Gabriel, apreendido no momento da abordagem policial, foi objeto de perícia (fls. 119/132), tendo sido constatada que, efetivamente, o acusado era traficante de entorpecentes. Afirmações como "fui para qbd fazer dinheiro" (fl. 126) e "sou do corre" (fl. 129), bem como mensagens recebidas por supostos usuários como "E ai parça? O que faz de bom? Tá na boca?" (fl. 130) comprovam, de modo irretorquível, a intensa traficância de drogas praticada pelo acusado.

Diante desse cenário, sobretudo levando em consideração as palavras dos policiais militares e o laudo pericial confeccionado a partir da apreensão do aparelho celular, a autoria em relação ao denunciado resta, portanto, de todo comprovada nos autos, restando evidente a ciência e a conduta de trazer consigo a droga.

No tocante à tipicidade do crime de tráfico de drogas em si, dentre outras modalidades descritas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, incrimina-se a conduta de trazer consigo, bastando que a finalidade do agente não seja para consumo próprio.

E, no caso em apreço, afastam-se as teses defensivas de absolvição por ausência de provas e de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo próprio.

Inferi-se do auto de exibição e apreensão e do laudo de constatação provisória acostados aos autos (fls. 11/2 e 37/8) que foram apreendidos em poder do réu 4,9 gramas de cocaína, acondicionados em doze embalagens plásticas; 6,84 gramas de maconha, acondicionados em duas embalagens plásticas; e 0,95 gramas de cocaína, na forma de "crack", acondicionados em dez embalagens plásticas.

De fato, não se trata de uma quantidade tão elevada de entorpecente. Contudo, aliada às demais circunstâncias em que ocorreu o flagrante, especialmente a variedade de droga, a forma de acondicionamento das substâncias e a apreensão conjunta da quantia de R\$ 70,00 em espécie, bem como ao teor das mensagens contidas no aparelho celular apreendido com o réu, a quantidade não é ínfima o suficiente para tornar crível a versão de que o acusado é um mero usuário.

Ora, é certo que o usuário de drogas não adquire os entorpecentes diariamente, em pequenas quantidades, mas compra um montante determinado, prevendo que durará por pelo menos alguns dias. Todavia, no caso concreto, verifica-se, por mencionadas circunstâncias, que as substâncias estavam prontas para o comércio e para tal se destinava.

Por isso, não se mostra cabível acolher a alegação de que todo o entorpecente apreendido destinar-se-ia apenas ao consumo pessoal.

Dessa forma, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, assim como a subsunção dos fatos à figura típica do artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/2006, não há de se acolher as teses defensivas de absolvição, por insuficiência de provas, tampouco a de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, o conjunto probatório demonstra, especialmente pelo laudo pericial de fls. 89/91, que o tráfico era praticado nas imediações de locais mencionados no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, atraindo-se, por consectário, a causa de aumento respectiva.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o réu era sabedor de sua conduta e tencionava o comportamento proibido que cometia. Não existindo circunstâncias que possam conduzir à exclusão da ilicitude ou mesmo dirimir a culpabilidade do réu e, demonstrado o fato típico, antijurídico e culpável, a responsabilidade penal do acusado é medida que se impõe.

Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena segundo o método trifásico elaborado por Nélson Hungria.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, não extrapolou a normalidade do tipo.

Não há antecedentes a serem valorados. O réu é primário, conforme demonstram os documentos de fls. 106/7 e 108/9. Não há elementos acostados aos autos para permitir a aferição da personalidade do réu e a sua conduta social. O motivo do crime não refoge à normalidade nesse tipo de ilícito. As circunstâncias e as consequências são normais ao tipo penal. Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago, ou seja, não possui sujeito passivo determinado. Passando à análise específica das circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que a natureza e a quantidade da droga já foram sopesadas para fins de subsunção dos fatos ao delito de tráfico, razão pela qual deixo de valorá-las novamente, evitando-se bis in idem. Portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes de pena e incide em favor do réu a atenuante da menoridade relativa, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (art. 65, inciso I, do Código Penal). Mantenho, todavia, a pena intermediária no patamar outrora estabelecido, pois, à luz do entendimento previsto no Enunciado nº 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, há que se considerar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, consoante exposto na fundamentação. Assim, majoro a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), o que resulta no montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Destaque-se, no que tange ao reconhecimento de causa de diminuição de pena, que o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, prevê que “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. No caso em exame, o réu, que atingiu a maioridade em 10/03/2021, não tem direito à causa especial de diminuição de pena. Isso porque denota-se a dedicação a atividades criminosas desde tenra idade, especialmente ao tráfico de drogas, impeditivo legal para a concessão da causa redutora, consoante observa-se na certidão de fl. 45. Em consulta aos autos nº 1503259-13.2019.8.26.0664, constata-se que Gabriel foi condenado definitivamente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ocorrido em 24/07/2019, tendo-lhe sido imposta medida socioeducativa de internação, confirmada pelo Tribunal de Justiça. Ademais, compulsando os autos nº 1500303-53.2021.8.26.0664, vê-se que o réu foi condenado definitivamente também pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, ocorrido em 23/10/2020, tendo-lhe sido impostas medidas socioeducativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. Em intervalo aproximado de dois anos, o réu se envolveu, por três vezes, com o tráfico de drogas. Incabível, portanto, a aplicação da causa de diminuição.

À vista do quantum de pena e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ressalte-se que, embora deva ser considerado para fins de detração, na forma do artigo 42 do Código Penal, o período de prisão preventiva não se mostra suficiente para influenciar na fixação do regime inicial.

Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal).

Conquanto o STF já tenha declarado inconstitucional a proibição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 (quatro) anos, o que impede a sua substituição por medidas restritivas de direitos (artigo 44, I, do Código Penal).

Igualmente incabível a suspensão da execução da pena, porquanto superados os dois anos previstos no artigo 77, caput, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (artigo 387, IV, do Código de Processo

Penal), pois o crime é vago, não havendo vítima definida.

Por todas as razões expostas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu GABRIEL FERREIRA DE BARROS LUZ pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do Habeas Corpus nº 724.313/SP (fls. 187/193), o réu poderá recorrer em liberdade.

Condeno o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, na forma do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, os quais deverão ser revertidos diretamente ao Funad.

Transitada em julgado da presente condenação:

A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;

B) coloquem-se os bens e valores perdidos (fls. 11/12) à disposição da União (Funad);

C) expeça-se mandado de prisão e, cumprido, guia definitiva de cumprimento da pena;

D) intime-se o réu para pagar a pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal;

E) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e

F) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Votuporanga, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA